

1501039-75.2021.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Carolina Nicodemos Andrade

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... traziam consigo, para fins de tráfico, drogas, quais sejam, 14 (quatorze) porções de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, com massa de 15 gramas (quinze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, os réus, conluiados e visando à prática do crime de tráfico de drogas, estavam no local acima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

2ª Vara

Rua 12, 718, Guaíra-SP - cep 14790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501039-75.2021.8.26.0210 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501039-75.2021.8.26.0210

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2325632/2021 - DEL.POL.GUAIRA, 21691290 - DEL.POL.GUAIRA, 1186/21/205 - DEL.POL.GUAIRA, 2325632 - DEL.POL.GUAIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO FLORO DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Carolina Nicodemos Andrade

Vistos.

ANDRÉ GUILHERME FAGUNDES CARDOSO e LUIZ FERNANDO FLORO DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.3430/06, porque no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 15h00, na Avenida 33, esquina com a Rua 38, bairro Miguel Fabiano, nesta cidade, em concurso, com unidade de propósitos e identidade de designios, traziam consigo, para fins de tráfico, drogas, quais sejam, 14 (quatorze) porções de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, com massa de 15 gramas (quinze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, os réus, conluiados e visando à prática do crime de tráfico de drogas, estavam no local acima citado, trazendo consigo as drogas acima descritas, as quais estavam em poder de LUIZ FERNANDO. Ocorre que policiais militares

receberam a informação de que os denunciados, conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes, estavam praticando o mencionado crime na Avenida 33, esquina com a Rua 38, no bairro Miguel Fabiano, ponto para onde os militares, então, deslocaram-se.

Consta que ao chegarem, os policiais avistaram um indivíduo se aproximando dos denunciados e com eles conversando, momento em que entregou algo para ANDRÉ e pegou algo com LUIZ FERNANDO, deixando o local na sequência. Em razão do que presenciaram, os policiais deliberaram pela abordagem dos denunciados, encontrando com ANDRÉ a quantia de R\$ 38,00 (trinta e oito reais); já com LUIZ FERNANDO encontraram, mais especificamente em sua cueca, quatorze trouxas de maconha. Houve prisão em flagrante.

Realizada audiência de custódia (fls. 57/62), determinando-se a prisão preventiva apenas de LUIS FERNANDO, concedendo-se liberdade a ANDRÉ GUILHERME.

Denúncia recebida (fls. 119/120). Réus citados. Defesas Preliminares (fls. 169, 177/186). Decisão afastando absolvição sumária (fls. 198/202).

Na instrução da causa foram ouvidas testemunhas, interrogando-se os réus ao final. Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia. As defesas requereram, em suma, que a absolvição se dê por falta de provas, não caracterização do tráfico de drogas. Subsidiariamente, desclassificação para o artigo 28; e que se conceda aos réus as benesses legais em caso de imposição de pena.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante e documentos que o acompanham, notadamente o auto de apreensão (fls. 10/11), auto de constatação (fls. 12), laudo pericial (fls. 128/129), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Com efeito, a testemunha BRUNO BEMFICA NOGUEIRA, policial militar, declarou que ambos já eram conhecido por traficar, e no dia houve uma denúncia do local, de tráfico, e que eles estariam traficando; foram ao local e viram os dois réus fazendo contato com outro indivíduo negro que não foi identificado, eles estavam conversando, num dado momento o André pegou algo desse indivíduo e parecia dinheiro, e o Luiz Fernando entregou algo; percebendo a viatura todos tentaram fugir, sendo possível abordar somente os réus, com Luiz estava a droga e com André estava o dinheiro; ambos costumam ser vistos em lugares de tráfico; terceiro indivíduo não foi identificado.

A testemunha TARCÍSIO BALTAZAR DE OLIVEIRA, policial militar, prestou declarações no mesmo sentido, ratificando o que dito pela testemunha anterior no sentido de que ambos foram vistos nas circunstâncias narradas na denúncia, com eles sendo apreendido dinheiro e droga. Disse que em patrulhamento houve denuncia anônima dizendo que ambos estariam traficando no cruzamento da 33 com a 38, sendo local conhecido por diversas ocorrências de tráfico; foram ao local e presenciaram o contato de ambos com um terceiro indivíduo, que teve constato com André entregando algo para ele, e recebendo algo de Luiz Fernando; que com este estava a droga apreendia e com aquele o dinheiro; que como disse acima quem estava com dinheiro era o André, ele foi visto recebendo o dinheiro; e quem entregava a droga era Luis Fernando; estavam em conjunto os dois réus naquele momento; o terceiro não foi identificado pois empreendeu fuga a pé; optaram por abordar os dois que são réus agora.

Em seu interrogatório o réu LUIZ FERNANDO FLORO DE SOUZA declarou que a droga era realmente sua, mas tinha comprado para usar, tinha acabado de sair da clínica para desintoxicação, de onde foi desligado por ter sido pego usando drogas; sobre estar em companhia do corréu na hora dos fatos, disse que se encontraram e chamou para fumar um baseado juntos, e ele topou, estavam esperando uma amiga quando foram enquadrados; sobre o terceiro indivíduo disse que se tratava de uma mulher, que é "sapatona", mas não era ela que ia vender a droga, a droga já tinha sido adquirida; é viciado em drogas cocaína e maconha, isso desde pequeno, uns 13 anos de idade; já esteve internado em clínica por duas vezes;

Em seu interrogatório o réu ANDRÉ GUILHERME FAGUNDES CARDOSO declarou que ele e o

colega estavam subindo juntos quando viraram e se depararam com a viatura e já abordaram, revistaram e não encontraram nada; o dinheiro estava com o Luis Fernando, não tinha nada, nem droga nem nada; eles desceram até o quarteirão de baixo e já subiram com 14 balinhas de maconha e mandaram algemar os dois; perguntou o motivo da prisão; eles jogaram a droga no seu parceiro; que iam na Lagoa usar maconha; mas não tinha dado tempo de comprar a droga ainda.

Observa-se a contradição relevante nos interrogatórios, eis que LUIS FERNANDO declarou que estava na posse da droga, pois já haviam adquirido para usar juntos, ao passo em que ANDRÉ GUILHERME declarou que pretendiam usar drogas, mas que ainda não haviam comprado nada e por isso não havia droga em poder de nenhum deles.

Por sua vez, os policiais narraram em detalhes como se deram os fatos.

Seus depoimentos foram coerentes e se harmonizam com a narrativa feita à autoridade policial, razão pela qual merecem credibilidade. Ressalte-se que não há razões para que o depoimento dos policiais seja desconsiderado, pois prestaram depoimento na condição de testemunhas compromissadas, devendo aos seus depoimentos ser atribuído o valor devido, mediante o cotejo com as demais provas dos autos.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "O depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição de funcional." (RT 752/589) "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7) "É de se asseverar que o simples fato das testemunhas de acusação serem policiais não é obstáculo para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos e seus depoimentos serão considerados como qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsearem a verdade, a não ser cumprirem com seus deveres funcionais. É óbvio que pelas múltiplas atividades desenvolvidas pelos policiais, seria demasiado rigor exigir-se a pompa de testemunhas presenciais, quando se sabe que o usual é a recusa de estranhos para testificarem o caso. Por outro lado, é de sabença generalizada que, em locais onde se cometem os delitos impera a lei do silêncio, principalmente em se tratando de tóxicos" (RT 732/622 - grifei).

Necessário ponderar, por oportuno, que eventuais divergências sobre detalhes dos fatos decorrem da diversidade de impressões que cada testemunha tem dos fatos.

Além disso, em razão do tempo decorrido e da quantidade de ocorrências atendidas, perfeitamente compreensível que as testemunhas não se lembrem de todos os detalhes dos fatos. Trata-se, no entanto, de detalhes que não afetam a essência da narrativa fática que as testemunhas de acusação fizeram, sempre de forma coerente e harmoniosa.

A propósito do tema, deve-se ter em conta, a princípio, que o tráfico de drogas é crime que fomenta a violência, seja através de outros delitos que dele derivam (furto, roubo, homicídio etc), seja em razão do controle que criminosos acabam por impor às comunidades em que se instalam, com vistas a garantir a perpetuação de um estado de impunidade.

Nesse contexto, é natural que aqueles que fazem denúncias sobre a ocorrência de um crime optem por não serem identificados, sob pena de colocarem suas próprias vidas em risco, sobretudo porque os mecanismos de proteção a testemunhas são escassos e, algumas vezes, falhos. Atento a esse cenário, criou-se o chamado "disque denúncia", que serve como incentivo para que cidadãos denunciem a prática de crime, porquanto pautado na garantia do sigilo da identificação do denunciante.

E mais, a existência da denúncia anônima não corrompe a prova, tampouco afasta a investigação policial.

Não há que se falar em nulidade por conta da ação policial, na medida em que os relatos dos policiais mostraram-se coerentes e harmônicos. Há que se observar, ainda, que a simples condição de usuário, ainda que efetivamente demonstrada, não afasta a responsabilidade pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, principalmente quando o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas de que o

entorpecente apreendido destinava-se à entrega a terceiros.

Irrelevante, por fim, a flagrância na prática de atos de venda. De fato, “para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).

O crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Ademais, o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é unissubsistente, de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele descritas encerra a concretização do delito, o que, por efeito, obsta sua ocorrência na modalidade tentada.

Nesse contexto, dou por afastadas as teses defensivas, tendo-se por provada a materialidade e autoria do crime, e passo à aplicação da pena.

Para LUIS FERNANDO, na primeira fase, conforme FA e certidões de fls. 39/41, verifica-se que o acusado possui maus antecedentes e, ainda que assim não se entenda, é certo que os diversos registros criminais apontam sua personalidade voltada à prática de ilícitos, de modo que se justifica a elevação da pena em 1/6, resultando 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Para ANDRÉ GUILHERME fixo a pena base em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, por sua primariedade técnica.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (artigo 61, I, CP), para LUIZ FERNANDO, consoante certidões e folha de antecedentes retromencionadas, especificamente por condenação irrekorribel nos autos n. autos nº 0001787-94.2015.8.26.0210 – fls. 39), aumentando-se a pena em mais 1/6 resultando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa. Para ANDRÉ GUILHERME resta a pena no mesmo patamar, ante a ausência de agravantes e atenuante.

Na terceira fase, quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ratifico o que acima dito, no sentido de que o acusado LUIZ FERNANDO é pessoa envolvida com a criminalidade, dedicando-se ao cometimento de crimes, especificamente, o tráfico de drogas, sendo reincidente, de modo que não cabe falar em redução de pena. Tal benefício é garantido apenas aos acusados primários e de que não se tenham informações sobre envolvimento com práticas criminosas, não sendo este o caso do réu que, aliás, foi descrito pelos policiais militares como sendo praticante recorrente de tráfico de drogas. De modo que referido benefício é cabível somente ao acusado ANDRÉ GUILHERME, para quem se reduz a pena em grau máximo, para resultar 1 ano e 8 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR, os réus LUIZ FERNANDO FLORO DE SOUZA e ANDRÉ GILHERME FAGUNDES CARDOSO, qualificado nos autos, incursos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 à pena de: 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, o primeiro; e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 500 (quinhentos dias-multa) fixados no patamar mínimo legal, para o segundo.

No caso concreto, para LUIZ FERNANDO em que a pena supera o patamar de quatro anos de reclusão, e em face da reincidência, a pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritivas de direitos, em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos acima indicados, fixo o regime fechado em razão da natureza hedionda do delito de tráfico de entorpecente, bem ainda pela reincidência do acusado. Neste sentido, vale menção ao seguinte precedente:

“Por fim, mantenho o regime inicial fechado para início do desconto da corporal, sendo o único compatível com o delito, dada a determinação legal em se tratando de crime hediondo (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90). Cumpre observar que o ilícito do

qual ora se trata, equiparado a hediondo, tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado permitirá aos réus uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta.” (TJSP, 4ª Câmara Criminal, AP 0002479-41.2010, Rel. Edison Brandão, j. 02/07/2013).

LUIZ FERNANDO não poderá recorrer em liberdade pois esteve preso durante toda a instrução da ação penal, sendo, o réu, reincidente e com vasta folha de registros criminais, a representar perigo concreto à ordem pública. No mais, note-se que, a despeito da redação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, modificada pela Lei nº 12.736/12, o réu não faz jus à imposição, diretamente pela Sentença de primeiro grau, do regime aberto ou semiaberto, em razão da detração para fins de regime prisional, pois ausentes elementos suficientes nos autos para sua concessão. Para tal fim, impõe-se a análise da presença de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, notadamente o subjetivo, que é verificável apenas perante o Juízo das Execuções Criminais, responsável por dirigir e fiscalizar o cumprimento da pena.

Para ANDRÉ GUILHERME, ante a primariedade e a quantidade de pena imposta, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, a teor do art. 33, §2º, b, do Código Penal, diante da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017). Tratou-se, evidentemente, de controle difuso de constitucionalidade, despidido de formal eficácia vinculante erga omnes, até que, eventualmente, exista o procedimento previsto no art. 52, X, da Constituição. Por outro lado, ainda que assim não fosse, o STF também entendeu que o chamado tráfico privilegiado não pode ser equiparado aos crimes hediondos (STF, HC 118.533, j. 23.06.2016).

Ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, revejo-o para me curvar a essas orientações, tomadas pelo Pleno da Suprema Corte, em atenção aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, importantíssimos à coesão de nosso Estado de Direito, já que o papel do STF deve ser modernamente compreendido como Corte Suprema de promoção da unidade do Direito (em especial, questões de Direito Constitucional), mediante a formação de precedentes.

Pelas mesmas razões acima expostas, e considerando o disposto na Resolução SF nº 5/12, entendo que se encontram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. Assim, pese embora meu entendimento pessoal, substituo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, quais sejam (i) a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a serem definidas em sede de execução e (ii) a prestação pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo a instituição pública ou privada de destinação social a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais. Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Este, poderá recorrer em liberdade.

Para ambos, e nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, de valores apreendidos nos autos, bem como de eventuais objetos relacionados no auto de exibição e apreensão, respeitado neste caso eventual direito de terceiro de boa-fé, pois são instrumentos, produtos ou proveito do crime em apreço.

Após o trânsito em julgado:

- a) lançamento do nome dos condenados no rol dos culpados;
- b) comunicação à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF);
- c) Expedição de guia de recolhimento definitiva, se o caso.

Sem prejuízo, havendo Habeas Corpus pendente, comunique-se com urgência o E. TJSP acerca da prolação desta sentença.

Isentos de custas.

Publique-se. Intime-se.
Guaíra, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA